

1501013-88.2019.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9 - Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501013-88.2019.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501013-88.2019.8.26.0617

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON DA SILVA SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Vistos.

WASHINGTON DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10 de junho de 2019, por volta das 08h57, na Rua Balbino Gonçalves, 100, Vila Guarani, em São José dos Campos, estaria trazendo consigo porções de maconha e cocaína, sem autorização.

Narra a denúncia que guardas civis municipais faziam ronda quando avistaram o acusado com uma sacola nas mãos. Ao perceber a viatura, ele dispensou a sacola e correu. Ele foi abordado e na sua posse foi apreendido um celular. Na sacola dispensada, foram encontradas 16 cápsulas de cocaína e 16 buchas de maconha, além de R\$ 21,00.

O acusado foi preso em flagrante e a prisão foi relaxada (fls. 28/29).

O acusado não foi localizado no endereço dos autos e foi notificado por edital (fls. 99). O defensor público apresentou defesa prévia (fls. 120/124) e a denúncia foi recebida em 13 de julho de 2020 (fls. 133).

O acusado foi citado por edital (fls. 141), o processo foi suspenso na forma do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 154) e foi decretada a sua prisão preventiva.

O acusado foi preso em 24 de janeiro de 2021, mas a comunicação ocorreu apenas em 22 de novembro de 2021 (fls. 177/178), o que provocou o relaxamento da prisão por excesso de prazo (fls. 208 e 222/225).

O acusado foi citado pessoalmente em 10 de dezembro de 2021 (fls. 227).

Durante a instrução, foram inquiridas testemunhas e o acusado foi interrogado.

Em memoriais, a promotora de justiça requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa requereu o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada pelos guardas municipais, uma vez que, desvirtuando-se de sua função, praticaram diligência investigativa ao realizar a abordagem por mera suspeita do acusado. No mérito, requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a detração da pena e a substituição da pena de prisão por restritivas de direitos e a aplicação da pena de multa na forma do art. 49 do Código Penal.

É o breve relatório.
Decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

As drogas foram apreendidas e periciadas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 04/05 e laudo de de exame químico-toxicológico de fls. 138/140, com resultados positivos para maconha e cocaína.

Em juízo, o guarda civil Jonas disse não se lembrar de detalhes da ocorrência devido ao decurso do tempo. Disse que estavam em patrulhamento com a viatura quando viram um rapaz com uma sacola nas mãos. Ao vê-los, o rapaz saiu do local rapidamente, o que estranharam. Enquanto corria, ele dispensou a sacola que segurava. Conseguiram alcançá-lo. Perguntaram ao rapaz por que ele havia saído e ele confessou que estava vendendo drogas. Na sacola encontraram uma pequena quantidade de drogas e, salvo engano, uma pequena quantia em dinheiro. Não conhecia o acusado. Ele não deu detalhes de como praticava o tráfico. Ele não aparentava estar sob efeito de drogas. Não viu outras pessoas no local. Na ocasião, nenhum adolescente foi apreendido.

O guarda civil Ulisses disse que viram o acusado num cruzamento com uma sacola nas mãos. Ante a aproximação da viatura, o acusado dispensou a sacola e iniciou fuga. Em buscas pessoais, nada encontraram de ilícito, mas o acusado, indagado, confessou que estava vendendo drogas. Pelo que se lembra, o acusado estava parado quando o avistaram. Não se lembra de terem abordado outra pessoa além do acusado. O acusado não aparentava estar sob efeito de drogas. Não tinha conhecimento de que o local era de tráfico. Abordaram o acusado porque ele se assustou e fugiu. Não se lembra porque estavam passando pelo local. É possível que estivessem cortando caminho em razão do trânsito.

Na delegacia de polícia, o acusado negou o tráfico. Alegou que estava no local para comprar um pino de cocaína. Portava uma porção de maconha para consumo próprio. Negou ter corrido. Em juízo, disse que estava sob efeito de drogas. Passou na biqueira para pegar uma bucha de maconha e um pino de cocaína, contudo, não tinha cocaína. O guarda civil apareceu e os outros três rapazes que estavam no local correram. Não correu. Eles conseguiram abordar apenas um adolescente, que confirmou que estava no local para comprar drogas. Eles o levaram para a delegacia e o

adolescente foi levado para a DIJU. Não dispensou nenhuma sacola. Estava somente com uma bucha de maconha e com R\$ 10,00 em dinheiro. Soube depois que o adolescente foi mandado para a Fundação Casa. Sabe disso porque encontrou-o na rua posteriormente. Conhecia-o de vista do local. Salvo engano, ele se chama Gabriel. Tem 23 anos. Faz bicos como ajudante de servente. Enquanto adolescente, teve ato infracional por roubo.

A prova não convence da prática do delito pelo acusado.

A prisão do acusado pelos guardas municipais foi ilegal. Ao abordarem o acusado, sem que houvesse evidências de um delito, eles extrapolaram a função constitucional que lhes cabe, consistente na proteção do patrimônio municipal.

Os guardas municipais estavam passando pelo local por uma eventualidade, para evitarem o trânsito. Eles alegam que o acusado assustou ao ver a viatura e correu, o que o acusado, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou. O acusado alegou que estava no local para comprar drogas e negou ter corrido e dispensado a sacola. Ele alegou que também um adolescente foi abordado e reportou que outras três pessoas correram.

Não havia flagrante delito. Uma pessoa comum não poderia, naquele contexto, ter revistado e prendido o acusado e a guarda municipal, que não se confunde com polícia ostensiva, tampouco poderia tê-lo feito.

Nesse sentido, decidiu recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça (RE n. 1977119 - SP, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Julgado em 07/06/2022):

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

1 - A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras "polícias municipais", mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte - apesar das investidas em contrário - por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal.

2 - Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil - em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência - estão sujeitas a rígido controle correcional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais - apesar da sua relevância - não estão sujeitas a nenhum controle correcional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de ser ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal.

3 - Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar - em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais - o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros.

4 - A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para “Polícia Municipal”. Ademais, inúmeros municípios pelo país afora – alguns até mesmo de porte bastante diminuto – estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas.

5 - A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito.

6 - Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.

7 - Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações.

8 - É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9 - Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais – e por isso interpretadas restritivamente – nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas

típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária.

10 - Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito. 11. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola oculta pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese. 12. Recurso especial provido.

Assim, reconheço a nulidade da abordagem e, em consequência, absolvo o acusado.

Posto isso, julgo improcedente a pretensão punitiva e ABSOLVO o acusado WASHINGTON DA SILVA SANTOS nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, restitua-se o valor apreendido ao acusado.

P.I.C.

São José dos Campos, 1º de novembro de 2022.

Sentença assinada digitalmente